

LIBERTES PUBLIQUES

Par BARIMAHEFASOA Nomena Fandresena
Conseiller près du Conseil d'Etat de la Cour Suprême

INTRODUCTION

Section 1 : Cadre juridique

- Constitution malagasy du 11 décembre 2010
- Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (résolution 217 A (III)) avec 58 états, traduite en 500 langues
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 ; ratifié le 21 juin 1971
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ratifié le 22 septembre 1971
- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 ratifié le 17 mars 1989
- Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifié le 19 mars 1991
- Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 10 décembre 2008
- Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
- Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort du 15 décembre 1989
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, entré en vigueur le 21 octobre 1986, ratifié le 9 mai 1992
- Les lois de ratification, lois d'application et les divers textes réglementaires
- Les jurisprudences des cours internationales, régionales des droits de l'homme ainsi que celles de la haute cour constitutionnelle et des juridictions ordinaires

Section 2 : Approche du concept de libertés publiques

Paragraphe 1 : Essai de définition

La notion de libertés publiques est une notion complexe et ambiguë. C'est un concept juridique qui n'a pas fait l'objet de définition dans le droit positif, même la Constitution malgache du 11 décembre 2010 renvoie à des notions diverses. Tantôt elle parle de droits de l'homme, de droits inaliénables ou de libertés fondamentales ou des droits et devoirs des citoyens.

Des auteurs ont essayé de la définir les libertés publiques mais n'ont pas trouvé d'intitulé uniforme.

Etymologiquement, les libertés publiques sont formées par la combinaison de deux termes : libertés et l'adjectif public.

Problématique : Tous ces termes recouvrent-ils la même notion ?

Libertés publiques : Liberté (faculté, autodétermination d'un individu) + Publique (intervention du pouvoir public)

➤ LIBERTE :

Selon LALANDE, la liberté est : « L'état de celui qui fait ce qu'il veut et non ce que veut un autre. C'est l'absence d'une contrainte étrangère ».

D'après le dictionnaire Le Robert, la liberté, c'est au sens strict : « la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance absolue de quelqu'un » ; au sens large : « la possibilité d'agir sans contrainte » et au sens politique et social : « le pouvoir d'agir au sein d'une société organisée selon sa propre détermination et dans la limite des règles définies ».

On assiste à un passage de la liberté au sens philosophique au sens de la liberté encadrée par des règles.

L'essentiel à retenir est donc que la liberté est l'autodétermination d'un individu. C'est une faculté en vertu de laquelle l'individu choisit son propre comportement. La reconnaissance de l'autonomie à l'individu lui permet de faire un libre choix et on peut porter atteinte à ce libre choix. Ce qui implique aux autres membres de la société, une obligation de respecter cette liberté. Cette obligation s'impose à la fois aux pouvoirs publics et aux autres individus. L'Etat ne doit pas s'immiscer dans les libertés des individus et ces derniers ne doivent pas s'immiscer dans les libertés d'autrui.

➤ PUBLIC :

L'adjectif public implique l'intervention du pouvoir qui consacre l'existence des libertés qui impose les libertés par la législation, qui sanctionne les violations de ces libertés dans les rapports entre l'individu et l'autorité publique et entre les particuliers eux-mêmes.

Lorsque les autorités publiques garantissent le respect des libertés, celles-ci deviennent des libertés publiques.

C'est l'intervention du droit positif, à travers sa reconnaissance par une norme juridique d'une valeur au moins législative qui fit d'une liberté une liberté publique.

Mise à part cette reconnaissance, l'intervention du pouvoir public peut se manifester sous forme de deux obligations :

INTERVENTION DU POUVOIR PUBLIC	Obligation négative	Respect des droits et libertés Non-ingérence/ Abstention Ex : liberté de conscience, liberté d'opinion
	Obligation positive	Fournir des prestations positives de la part de l'Administration (fourniture de biens et de services) Ex : droit à la santé, droit à l'enseignement

Résumé :

Les libertés publiques sont des pouvoirs d'autodétermination qui visent à assurer l'autonomie de l'individu et qui sont reconnus par des normes juridiques et bénéficient d'un régime juridique de protection renforcé à l'égard des autres individus et des autorités publiques.

Ainsi, on a 5 éléments de définition des libertés publiques :

Pouvoirs d'autodétermination	Pouvoirs que l'individu exerce lui-même sans que l'intervention d'autrui ou de l'Etat ne soit toujours nécessaire
Visant à assurer l'autonomie de l'individu	Absence de contrainte sociale, de contrôle étatique (alors, les libertés publiques sont-elles absolues ?)
Reconnaissance par des normes juridiques	Les libertés publiques sont consacrées et protégées par le droit contre les arbitraires du pouvoir
Bénéfice d'un régime juridique de protection renforcé	Mise en place de plusieurs garanties : juridictionnelles ou non juridictionnelles
Protection s'impose à l'égard des autres individus et des autorités publiques	Exigence de la mise en place d'un Etat de droit (les libertés publiques ne peuvent se développer dans un Etat de police : les règles de droit ne s'appliquent qu'aux personnes privées)

Paragraphe 2 : Les notions connexes

1. La distinction entre droit et liberté

DROIT	LIBERTE
Droit de créance vis-à-vis de la société/ Exigibilité Exige plus qu'une protection Obligation positive : service/ prestation	Autodétermination/ Faculté/ libre arbitre N'exige qu'une protection Obligation négative de la part des pouvoirs publics

2. La distinction entre droits de l'homme et libertés publiques

Les droits de l'homme et les libertés publiques sont deux notions proches, mais qui ne doivent pas être confondues.

Les droits de l'homme relèvent de la conception naturelle selon laquelle : puisque l'individu est un homme, il possède un certain nombre de droits inhérents à sa nature humaine. C'est la faculté d'agir reconnue à l'individu en naissant et qui est antérieure à toute institution publique ou privée. Les droits de l'homme sont généralement centrés sur l'homme.

Ex : le droit à la vie, droit de vote (est-ce un droit naturel : postérieur à la société et nécessite l'intervention d'une personne publique)

De cette notion de droit naturel liée à la personne humaine indépendamment des pouvoirs publics, on passe à celle des libertés publiques qui sont des droits humains reconnues par la Constitution, la Loi, mais aussi par les conventions internationales. Les libertés publiques relèvent de leur reconnaissance et intégration dans le Droit positif.

Ainsi, toutes les libertés publiques sont des droits de l'homme, mais tous les droits de l'homme ne sont pas tous des libertés publiques.

Les droits de l'homme restent de simple conception ou proposition idéologique s'ils ne sont pas consacrés par le droit positif.

La particularité des Droits de l'homme :

Les droits de l'homme se rattachent à la philosophie des lumières du XVIIIème siècle en particulier au Contrat social de Jean Jacques ROUSSEAU.

- Aux Royaumes Unis, les premiers droits de l'homme ont été consacrés premièrement dans la Magna Carta de 1215 appelée "Grande Charte des libertés d'Angleterre" et affirme le droit à la liberté individuelle (Contrat passé entre le Roi et les grands féodaux). Elle consacrait la limitation de la toute puissance et du pouvoir sans limite du roi, le principe de légalité et le droit d'aller et venir. Deuxièmement, la Pétition des Droits de 1628 qui se réfère à la Magna Carta. Elle a souligné que le pouvoir du roi est limité par des droits et libertés individuelles par l'interdiction des arrestations arbitraires et l'interdiction de lever l'impôt sans autorisation du parlement. Troisièmement, le Bill of rights de 1689 promulgué comme loi du Royaume.

- En Amérique, la proclamation des droits de l'homme a été faite dans la déclaration d'indépendance du 04 juillet 1776. Cette déclaration comporte l'énoncé « tous les hommes sont créés égaux », mais cette affirmation n'entraîne pas l'égalité sociale, car il y avait les esclaves pour lesquels il n'y avait pas d'égalité même s'ils étaient créés par dieu et dans le Bill of rights de 1787, traduction des dix premiers amendements de la Constitution américaine.
- En France, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a été adoptée le 26 août 1789 qui énonçait les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.

Puis, il y a eu une extension des droits de l'homme sur le plan international. On assistait à l'internationalisation des droits de l'homme et son universalité a été consacrée le 10 décembre 1948 par l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La Déclaration n'a pas de valeur juridique. Elle fait partie du droit coutumier et constitue une source de droit.

La déclaration est dite universelle, car elle définit un idéal commun à atteindre par les Etats. C'est un texte sans frontière. Chaque nation peut trouver au sein de son système un moyen de la mettre en œuvre. La Déclaration, traduite en 200 langues, constitue un modèle qui bénéficie à tous les membres de la famille humaine sans distinction et valable pour tout peuple et individu à tout moment et à tout lieu.

Elle constitue un point commun et chaque culture apporte ses richesses pour relativiser les acquis et renforcer sa compréhension.

Paragraphe 3 : La classification des libertés publiques

Les libertés publiques ne sont pas divisibles. Il est difficile de trouver une classification susceptible de consensus.

1. La classification fonctionnelle ou situationnelle

C'est la distinction selon la manière dont les libertés publiques prennent en compte l'individu en tant que tel : un être humain, personne physique ou en tant que membre de la société ou en tant qu'acteur de la vie économique.

Les droits et libertés de l'individu personne, physique (libertés physiques) :	Les droits et libertés de l'individu membres de la société (libertés intellectuelles) :	Les droits et libertés de l'individu acteur de la vie économique (libertés socioéconomiques) :

Droits fondamentaux de l'homme en tant qu'être humain et à la sûreté. Ex : Liberté de disposer de son corps, liberté d'aller et venir, liberté et inviolabilité du domicile et de la correspondance.	Permettent à l'individu de communiquer avec les autres et d'agir avec eux. Ex : Liberté de conscience, liberté des cultes, liberté d'expression, liberté d'enseignement, liberté de presse et de la communication audiovisuelle, de manifestation, liberté d'association.	Recouvrent le libre choix et d'accès à la profession et les libertés sociales liées à la vie économique. Ex : Liberté de commerce et d'industrie, liberté syndicale, liberté de réunion, le droit d'accès à la fonction publique.
---	--	--

2. La classification bipartite entre les libertés individuelles et les libertés collectives

La distinction est faite entre les libertés qui intéressent personnellement l'individu en tant que tel et les libertés qui intéressent l'individu dans la vie économique et en tant que membre d'un groupe.

Les libertés individuelles sont celles qui intéressent l'individu en tant que personne physique et dont il jouit et peut exercer individuellement.

On peut distinguer parmi elles les libertés liées à la sûreté qui garantissent que le citoyen ne fasse l'objet d'arbitraire de la part du pouvoir public et d'autres membres de la société.

Quant aux libertés collectives, ce sont les libertés qui ne peuvent être exercées que si deux ou plusieurs personnes s'accordent à leur mise en œuvre ou en interaction avec d'autres membres de la société.

3. La classification par génération de droit

La classification par génération est faite en fonction de l'apparition et de la reconnaissance des droits et libertés dans la société.

1^{ère} génération : les droits civils et politiques

Les droits civils visent à garantir la liberté et l'autonomie de l'individu et qui n'exige dans la plupart du temps qu'une abstention ou une obligation négative de la part des pouvoirs publics.

Les droits politiques sont quant à eux les droits liés à la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques de l'Etat. En principe, seuls les nationaux en bénéficient, mais aucune règle du droit international n'interdit aux Etats d'accorder ses droits aux étrangers.

2^{ème} génération : les droits économiques, sociaux et culturels

Ils impliquent une obligation positive et une intervention active et concrète de l'Etat puisqu'ils exigent une intervention financière. Leurs reconnaissance, garantie, et effectivité dépendent du développement économique et social de l'Etat.

3^{ème} génération : les droits de solidarité

Ce sont de nouveaux droits de la personne apparus il y a une vingtaine d'années avec les évolutions technologiques et les évolutions de la société. Ce sont principalement les droits liés à la protection de l'environnement, l'appartenance à un monde unique et à l'existence de patrimoine commun à protéger et à la protection des minorités sociales.

Section 3 : Les titulaires des libertés publiques

Paragraphe 1 : Les individus, personnes physiques

Auparavant, il y avait une distinction entre les hommes et les femmes, les maîtres et les esclaves, mais depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les individus sont égaux en droit et en liberté.

Cependant, est-ce que tous les individus jouissent réellement des mêmes libertés ?

Paragraphe 2 : Les personnes morales

On doit faire la distinction entre personne morale de droit public et personne morale de droit privée.

Les personnes morales de droit privé en l'occurrence les entreprises, associations ou autres groupements possèdent une large gamme de droits et libertés comme les personnes physiques à quelques exceptions près. Elles jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux personnes physiques mis à part les droits et libertés inhérents à la personne humaine.

Les personnes morales de droit public jouissent également de droits et libertés au même titre que toutes les personnes morales de droit privé, mais leur étendue diffère eu égard les prérogatives accordées et le but assigné à ces dernières.

Et les animaux et les végétaux sont-ils titulaires de libertés publiques ? Qu'en est-il du droit à un environnement sain, écocide dont le but est de protéger la faune et la flore ? Qu'en est-il de l'institution de taxe sur les animaux domestiques, assurances pour les animaux domestiques : reconnaissance d'une personnalité juridique aux animaux et végétaux ?

CHAPITRE I : LE STATUT JURIDIQUE DES LIBERTES PUBLIQUES

Selon l'article 6 de la Constitution malgache de 2010 : Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion.

De cette disposition, on peut faire deux remarques :

- L'article 6 traduit l'égalité entre les hommes (égalité de genre) et consacre le principe de non-discrimination; tous les individus sont placés sur le même pied d'égalité (article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme), seules les personnes vulnérables jouissent de protection spécifique (discrimination positive) ;
- Les libertés ne sont pas absolues puisqu'elles sont restreintes et limitées dans certains cas (intérêt général, ordre public, intérêt national, sécurité nationale) ;

Les libertés publiques sont aussi soumises à de nouveaux pouvoirs : pouvoir bureaucratique (pouvoir public) pouvoir médiatique (médias) pouvoir scientifique (évolution de la technologie et de la société).

Section 1 : Les procédés de reconnaissance des libertés publiques

Paragraphe 1 : Les sources nationales et valeur juridique des libertés publiques

A. La constitutionnalisation des libertés publiques

L'adoption d'une constitution marque le début d'une ère de liberté pour un pays. La constitution est considérée comme la gardienne des libertés publiques puisque c'est le principal instrument qui engage les organes de l'Etat pour mettre en œuvre les garanties des droits et libertés des citoyens.

Par la proclamation des libertés publiques et les garanties qu'elle offre, la constitution constitue la charte des libertés publiques. Les droits et libertés insérés dans la constitution ne peuvent être remis en cause que par de procédures rigoureuses.

A Madagascar, les Constitutions qui se sont succédé depuis l'indépendance ont reconnu des libertés publiques à leur manière à la population. Dans la Constitution de 1959, les libertés publiques avaient une large place dans le préambule que dans le corps de la Constitution elle-même. Seuls 03 articles du texte de la constitution touchaient les libertés publiques (notamment l'article 2 sur la neutralité de l'Etat envers les églises – article 3 sur le système de suffrage universel direct et indirect et enfin en son article 6 sur la libre formation et libre exercice des partis politiques.

Dans la Constitution de 1975 qui avait une valeur inférieure à la charte de la révolution socialiste – on assistait à une conception socialiste des libertés publiques. 32 articles du titre II ont été consacrés aux libertés publiques. Ces dernières ne sont reconnues que pour la reconstruction du socialisme et mettant l'accent sur les devoirs socio-économiques de l'individu. L'exercice des libertés publiques était limité par la construction du socialisme.

Dans la Constitution de 1992 qui a adopté une conception plus libérale et plus positiviste des libertés publiques. 32 articles ont été consacrés aux libertés publiques et leur exercice était limité par le respect des droits d'autrui et les impératifs d'ordre public.

Dans la Constitution de 2010 : avec une conception libérale et positiviste des libertés publiques, 33 articles sont consacrés aux libertés publiques. Le premier sous-titre du Titre II est consacré aux droits civils et politiques et le second sous-titre aux droits économiques socioculturels. L'exercice des libertés publiques est limité par le respect des droits d'autrui et les impératifs d'ordre public.

Parmi les droits et libertés reconnus par la Constitution de 2010, ci-après ceux reconnus en matière de justice :

- L'interdiction de l'arrestation arbitraire, l'inviolabilité du domicile sans l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, sauf le cas de flagrant délit et l'interdiction de violation du secret de correspondance
- La non-rétroactivité de la loi pénale
- Le respect du principe de non-bis in idem
- Le droit de tout citoyen au libre recours à la justice
- L'inviolabilité des droits de la défense à tous les stades de la procédure
- L'interdiction de la torture morale ou physique pendant l'arrestation ou la détention
- La présomption d'innocence
- Le caractère exceptionnel de la détention préventive

B. La consécration législative des libertés publiques

Le législateur est le meilleur protecteur des libertés publiques puisqu'il fixe les règles et les conditions d'exercice des droits et libertés reconnus par la Constitution. En effet, l'article 7 de la Constitution du 11 décembre 2010 dispose que : « Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi ».

Dans cette optique, le législateur dessine les frontières entre l'exercice des libertés publiques et la sauvegarde de l'ordre public et de l'intérêt général. Il est chargé de concilier les libertés individuelles avec la protection de la sécurité de tous, d'adapter le droit positif à l'évolution de la société en tenant compte des nouvelles aspirations de la société en fonction de cette évolution.

Les libertés publiques doivent être conformes à l'ordre social et aux besoins de la société.

A Madagascar, la majorité des lois adoptées par le Parlement est relative ou touche d'une manière ou d'une autre à un droit ou à une liberté.

C. L'importance du règlement dans le cadre de l'exercice des libertés publiques

L'autorité administrative intervient également dans la protection et surtout dans le cadre de l'exercice des libertés publiques. Elle a pour principale mission le maintien de l'ordre public qui constitue à la fois une condition d'existence des libertés publiques et une limite à ces dernières. Elle réglemente par conséquent l'usage des libertés publiques afin d'éviter les abus et les troubles.

Même si le législateur s'est prononcé sur les conditions d'exercice d'un droit ou d'une liberté, l'autorité administrative compétente conserve un large pouvoir d'appréciation pour faire cadrer la réglementation avec les impératifs locaux.

Au strict, un règlement est un acte pris par le pouvoir exécutif soit par le Président de la République en Conseil des Ministres soit par le Premier Ministre ou un ou plusieurs Ministre en Conseil du Gouvernement. En principe, c'est un acte de portée général et impersonnel pris dans le domaine du règlement fixé par la Constitution.

Dans ce sens, on fait la distinction entre règlement autonome et règlement d'application :

- Les règlements autonomes sont pris par le gouvernement sans qu'il y ait de loi dans les domaines prévus par la Constitution (c'est une compétence générale attribuée par la Constitution). Ils doivent être conformes à la Constitution.
- Quant aux règlements d'application, ils sont pris lorsqu'une loi demande expressément au Gouvernement d'adopter un décret pour son application. Ils sont pris pour préciser ou compléter une disposition légale.

Au sens générique du terme, ce sont les actes et les décisions pris par les autorités administratives qui au sommet, sont dirigées par le Président de la République jusqu'au niveau le bas de l'administration. Ils peuvent avoir une portée générale et impersonnelle (acte réglementaire) comme ils peuvent s'adresser à des personnes nommément désignées (acte individuel).

Ces actes réglementaires peuvent être pris en vertu de la compétence discrétionnaire de l'administration ou en vertu de sa compétence liée.

Dans le cadre de sa compétence discrétionnaire, l'action de l'administration est libre, pas entièrement réglementée par le droit, elle a un large manœuvre d'appréciation dans la prise de décision. Elle peut prendre ou refuser une demande pour des motifs d'opportunités.

On est dans le cadre de la compétence liée lorsque l'administration n'est pas tout à fait libre dans ses actions. Elle est strictement encadrée par le droit, il n'a pas de pouvoir d'appréciation. Lorsque les conditions sont remplies et lorsque la loi le prévoit, elle est tenue de prendre un acte ou faire droit à une demande. Le contrôle du juge diffère aussi en fonction de cette compétence, auparavant, le contrôle est restreint dans le cadre de la compétence discrétionnaire et maximum dans le cadre de la compétence liée alors que ça devrait être le contraire, car il y a plus de risques d'atteinte aux libertés publiques dans ce premier cas, puisque l'administration peut apprécier chaque situation et refusé pour des motifs d'opportunités qui est source de véritable inégalité dans la pratique.

Paragraphe 2 : La consécration internationale des libertés publiques

A. L'internationalisation des proclamations

Dans cette partie, on va plus revenir sur la reconnaissance des droits et libertés sur le plan international, parce qu'on a déjà vu ces textes dans le cadre des cadres juridiques, on va se focaliser sur la procédure d'adoption et d'intégration de ces normes juridiques internationales dans l'ordre juridique interne.

L'entrée en vigueur dans le droit positif d'un État d'un texte international se fait par le biais de la ratification.

On doit faire la distinction entre deux systèmes d'intégration : le système moniste et le système dualiste.

Dans le système moniste, l'acte juridique de ratification (loi ou décret) suffit à ce que le texte international soit intégré dans le droit positif et que ces dispositions soient invocables et applicables de plein droit sur l'ensemble du territoire national.

Quant au système dualiste, l'acte de ratification ne suffit pas pour l'applicabilité du texte sur le plan national, il faut que le parlement adopte une loi reprenant les dispositions du texte international pour que ses dispositions puissent être invoquées devant les juridictions et imposables à l'administration.

Pour le cas de Madagascar, on a adopté le système moniste, la loi de ratification suffit à elle seule pour que le texte international soit applicable et face partie intégrante du droit positif.

Cependant, l'application d'un texte international et particulièrement pour les actes bilatéraux, est soumise au principe de réciprocité, il faut que les parties appliquent respectivement les dispositions du texte pour être opposables.

A l'exception du droit international humanitaire, qui n'est pas soumis à cette réciprocité.

Maintenant, on va faire le parallèle entre la procédure d'adoption d'une loi et l'adoption d'un texte international et son entrée en vigueur dans le droit positif.

B. La logique de la régionalisation de la proclamation

La charte de l'organisation de l'unité africaine (OUA) du 25 mai 1963 prévoit l'institution d'un instrument africain de protection des droits de l'Homme. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée le 28 juin 1981. Elle est entrée en vigueur 03 mois après sa ratification par la majorité absolue des membres de l'organisation le 21 octobre 1986.

Madagascar a ratifié la charte le 09 mai 1992 en vertu de la loi d'autorisation n° 91-023 du 06 août 1991. La charte est entrée en vigueur sur le territoire de la république à partir du 19 juin 1992.

La charte présente 04 spécificités et un aspect novateur par rapport aux autres instruments :

- Par rapport aux autres instruments régionaux, elle énonce de nouveaux droits, notamment le droit des peuples à l'égalité, droit des peuples colonisés à la libération, le droit des peuples au développement, à la paix, à un environnement sain.
- La CADHP consacre à la fois des droits et des devoirs aux individus. Elle consacre un chapitre entier aux devoirs de l'individu. Pour certains auteurs, l'insertion des devoirs ne doit pas servir de prétexte à la limitation des droits individuels par des gouvernements répressifs.
- La charte tient compte des valeurs traditionnelles de la civilisation africaine, mais également des valeurs contemporaines. Elle se situe à mi-chemin entre tradition et modernité.
- La charte a institué 02 mécanismes de protection des droits de l'homme :
 - La commission africaine des droits de l'homme et des peuples
 - La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

La commission joue un rôle important dans la reconnaissance et la promotion des droits de l'homme. La cour se distingue par son double mandat : consultatif et contentieux.

Pour les questions concernant les femmes et les enfants, les préoccupations restent les mêmes au niveau africain. Les femmes font partie des groupes vulnérables au même titre que les personnes âgées, les mineurs et les aliénés mentaux et les personnes en situation de handicap. Ainsi, les femmes nécessitent une attention particulière et spéciale (au terme de l'art 18 al 3ème de la Charte). L'Etat a le droit de veiller à l'élimination de toutes discriminations et d'assurer la protection des droits de la femme énoncée dans les déclarations et conventions internationales.

C'est dans cette optique que furent respectivement adoptés en juillet 1990 et le 11 juillet 2003 la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes.

Section 2 : Les conditions d'existence des libertés publiques

Les libertés publiques ne peuvent exister que si elles sont fondées sur des principes de droit. On distingue 4 principes :

- Le principe de légalité
- Le principe de l'Etat de droit
- Le principe de démocratie
- La notion d'ordre public

Paragraphe 1 : le principe de légalité

Ce principe suppose le fait de se conformer à la loi et de se soumettre au droit qui est pris comme référence à la fois par le gouvernant et le gouverné dans leurs activités. Il constitue une garantie offerte aux administrés face aux éventuels abus de l'Administration.

Le principe de légalité a pour but de maintenir l'ordre social et l'équilibre des pouvoirs, favoriser le développement et préserver et protéger les libertés publiques.

Tout acte administratif contraire à la loi doit être constaté, annulé et considéré n'avoir produit aucun effet juridique.

Il y a illégalité ou violation de la loi quand l'acte pris contredit une règle de fond (violation de la loi proprement dite) ou quand l'auteur de l'acte n'est pas celui initialement prévu (incompétence de l'auteur de l'acte) ou quand la procédure instituée pour la prise de l'acte n'a pas été observée (vice de procédure) ou quand l'acte ne respecte pas la forme préétablie (vice de forme) ou quand l'objectif de l'acte dévie du but assigné par la loi en l'occurrence la satisfaction de l'intérêt général (détournement de pouvoir).

La loi permet à tout individu de se dresser contre tout acte estimé illégal de l'Administration par le biais du recours pour excès de pouvoir à intenter devant les juridictions administratives. Par ailleurs la légalité est une des conditions d'ingérence ou d'immixtion des pouvoirs publics dans l'exercice des libertés publiques. L'exercice d'un droit ou d'une liberté peut faire l'objet

de limitation ou de restriction, mais à condition de cette dernière soit prévue par la loi. C'est la condition de légalité.

Paragraphe 2 : le principe de l'Etat de droit

Ce principe a été développé par les juristes allemands du XIX^{ème} siècle. Un Etat de droit est celui dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes règles de droit et sous le contrôle d'une justice indépendante.

Selon Hans KELSEN, l'Etat de droit est un ordre juridique centralisé qui représente les traits suivants :

- Les juridictions et l'Administration y sont liées par des lois
- Les lois sont des normes générales édictées par un parlement élu par le peuple
- Avec ou sans collaboration, un Chef d'Etat est placé à la tête du gouvernement
- Les membres du gouvernement sont responsables de leurs actes
- Les juridictions sont indépendantes
- Les citoyens se voient garantir un certain nombre de droits et de libertés

Paragraphe 3 : le principe de démocratie

Il ne peut y avoir de véritables libertés publiques sans l'institution d'un régime politique adapté. Le régime démocratique libérale semble selon la doctrine le mieux adaptée.

Principes de garantie des libertés publiques, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de légalité et le principe d'égalité constituent également les bases essentielles d'un régime démocratique.

Cependant, et pour ce qui est du principe d'égalité, il connaît des limites. Il n'arrive pas à assurer un traitement identique à tout le monde. Cette relativité du principe d'égalité se manifeste à trois points de vue :

- L'égalité consacrée est parfois une égalité de droit ou une égalité juridique qui peut aboutir à une inégalité de fait ;
- L'égalité ne peut exister que si les situations sont identiques. Elle ne vaut que pour les personnes se trouvant dans la même situation ;
- L'égalité peut céder devant des considérations d'intérêt général et d'ordre public.

Sans préservation des libertés publiques, il ne peut y avoir de vie démocratique et les régimes démocratiques ne peuvent survivre en l'absence de libertés publiques.

Les éléments d'un régime démocratique se présentent comme suit :

- La démocratie est respectueuse de la personne humaine et de l'indépendance des différents pouvoirs ;
- La démocratie repose sur la limitation du pouvoir central au profit des collectivités territoriales ;
- La démocratie revendique au profit des citoyens l'organisation d'un droit et d'un régime de responsabilité dans le cadre de la gestion et de la direction des affaires publiques avec la mise en place des institutions nécessaires à cet effet ;
- La démocratie se fonde sur la laïcité de l'Etat ;

- La démocratie requiert la primauté du droit, l'instauration d'un Etat de droit et l'assainissement de la vie politique.

Paragraphe 4 : la notion d'ordre public

L'ordre public n'a pas fait l'objet de définition dans le droit positif alors que cette notion constitue à la fois une garantie pour l'exercice et l'effectivité des libertés publiques et une limite quant à l'exercice de ces dernières.

D'une manière simple, l'ordre public correspond à l'ensemble des règles préventives qui assure le fonctionnement de la société. C'est aussi la traduction de l'ordre social qui suppose la paix sociale, l'harmonie sociale. Sont contraires à l'ordre public, les actes et les faits contraires ou faits à l'encontre de ces règles ou à l'encontre des mécanismes instaurés par l'Etat.

CHAPITRE II : LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DES LIBERTES PUBLIQUES

Les libertés publiques s'exercent dans certaines conditions afin d'éviter de trop grande restriction de la part de l'Administration et d'abus de la part des individus. Il est important que leur exercice soit garanti et encadré.

Section 1 : L'encadrement des libertés publiques

Les libertés publiques peuvent être simplement encadrées ou limitées dans certains cas. D'une part, elles sont aménagées selon qu'elles sont mises en œuvre en période normale ou en temps de crise. D'autre part, les restrictions peuvent être apportées aux libertés publiques soit par la Constitution elle-même, soit par la loi soit par un règlement ou tout autre acte administratif.

Paragraphe 1: le régime juridique des libertés publiques

Le régime juridique applicable à un droit ou à une liberté est constitué par les règles selon lesquelles cette liberté peut s'exercer. La possibilité d'aménager les libertés publiques leur donne un aspect relatif. L'aménagement des libertés publiques ne se présente pas partout de la même manière, et ce à l'intérieur d'un pays donné. L'aménagement varie selon les libertés en causes et les circonstances (lieu, temps d'exercice et situation locale).

A. Le régime juridique en période normale

Les temps de paix ou d'harmonie sociale sont les plus propices à l'épanouissement des libertés publiques. Mais il ne peut exister de liberté absolue. Il existe diverses modalités de régime juridique des libertés publiques. Les auteurs distinguent 4 attitudes théoriques de l'administration face aux activités de l'individu desquelles on peut traduire 4 régimes des libertés publiques :

L'administration peut interdire une activité ce qui exclue l'idée de liberté qui correspond au régime d'interdiction

L'activité peut requérir une autorisation préalable de la part de l'administration avant son exercice : régime de l'autorisation préalable

L'activité doit être déclarée préalablement devant l'administration avant son exercice : régime de la déclaration préalable

L'administration n'intervient que pour sanctionner les abus et les manquements effectués dans le cadre de l'exercice de l'activité : régime répressif.

Ces 4 attitudes de l'administration peuvent être ventilées en 2 régimes juridiques :

- le régime préventif
- le régime répressif

1. Le régime préventif

C'est le plus restrictif et le plus sévère pour les libertés publiques puisque l'autorité compétente intervient avant même que l'activité ou le droit ou la liberté de l'individu ou du groupe ne s'exerce. L'autorité intervient pour réglementer l'exercice de la liberté. Le principe n'est pas la liberté, mais la restriction. La liberté devient ainsi l'exception et non la règle.

Le régime préventif est susceptible de plusieurs modalités. La plus radicale est le régime de l'interdiction. Dans ce régime, il n'y a pas de liberté. Son exercice est interdit.

La moins radicale est celle de l'autorisation préalable. Dans ce régime, l'accord ou l'autorisation de l'autorité administrative compétente est requis pour pouvoir exercer un droit ou une liberté. Ce régime peut entraîner de graves inégalités surtout dans la pratique puisque l'autorité compétente peut accorder des autorisations aux personnes qui lui apparaissent dévouées et le refuser à d'autres pour des motifs d'opportunités surtout si la délivrance de l'autorisation relève de la compétence discrétionnaire de l'administration.

La plus libérale est celle de la déclaration préalable. Dans ce régime juridique, l'exercice des libertés publiques n'est possible qu'après que l'intention d'exercer ait été déclarée à l'administration. Ce qui va permettre à cette dernière d'être informée de l'existence de l'activité pour mieux la surveiller et la protéger. L'administration peut jouer un rôle purement passif, elle se contente de recevoir la déclaration ou un rôle actif en délivrant un récépissé de déclaration ou en émettant des observations.

2. Le régime répressif

Dans ce régime, l'individu peut exercer librement ses libertés publiques sans que l'intervention d'une autorité administrative soit nécessaire. L'administration n'intervient qu'après usage du droit ou de la liberté et seulement pour protéger et sanctionner les abus. Les droits ou libertés sont généralement limités par le droit pénal et les abus sont appréciés pas seulement par l'administration, mais aussi et surtout par le juge. Les individus, dans leur activité sont censés connaître les limites de leurs libertés publiques en application du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi.

Le régime répressif est le plus libéral. Le principe est la liberté et la répression l'exception.

B. Le régime juridique des libertés publiques en période exceptionnelle

Une situation exceptionnelle ou une situation d'exception peut être déclarée face à des menaces graves à l'ordre public, à la sécurité de l'État, à l'indépendance de l'État, pour sauvegarder l'intégrité du territoire national ou en cas d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.

Elle a pour objectif de préserver la continuité de l'État et des services publics et le maintien de l'ordre public. Ainsi, les impératifs d'ordre public deviennent plus importants que l'exercice des libertés publiques.

Pour le cas de Madagascar, les situations d'exception sont régies par l'article 61 de la Constitution et par la loi n°91-011 du 19 juillet 1991 sur les situations d'exception.

Les régimes d'exception sont constatés par déclarés par le Président de la République en conseil des ministres après avis des Chefs d'institutions de la République.

Les situations d'exception ont pour effet d'une part, l'accroissement des pouvoirs du Président de la République qui peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. Il accumule tous les pouvoirs réglementaires, législatifs et gouvernementaux. Cependant, il peut procéder à des délégations au Premier ministre, aux ministres et aux services déconcentrés ou représentant de l'État territorialement compétent.

D'autre part, le parlement peut tenir une session extraordinaire et ne peut être dissout pendant toute la durée de la situation d'exception.

Sont réquisitionnés d'office, sans qu'il soit nécessaire de leur notifier une quelconque décision de réquisition, les services publics ou entreprises intervenants dans les domaines suivants: le ravitaillement, eau et énergie, les services de santé et hôpitaux, les services vétérinaires, le transport, la poste et télécommunication, radiodiffusion et télévision, service de la voirie, établissements bancaires, les services du contrôle financier, les services rattachés aux institutions, ministère des affaires étrangères, ministère de l'intérieur, ministère de la défense et de la sécurité publique, ministère des finances, ministère de l'élevage, agriculture et pêche et ministère de la justice.

Il existe trois types de situations exceptionnelles : l'état de nécessité nationale, l'état ou la situation d'urgence et la loi martiale.

1. La situation ou l'état d'urgence

Elle peut être proclamée soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, à la sécurité de l'État soit d'événements qui par leur nature et leur gravité présentent les caractéristiques d'une calamité publique.

La situation d'urgence peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire. Le décret de proclamation fixe les circonscriptions à l'intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle ne fait pas obstacle à la proclamation dans la même zone territoriale, de la loi martiale qui sera alors la seule appliquée. La durée d'une situation d'urgence est de 15 jours renouvelables indéfiniment pour la même durée.

2. L'état de nécessité nationale

Il peut être proclamé en cas de crise économique, politique ou sociale qui par son ampleur et sa gravité, constitue une menace pour l'avenir de la nation ou est susceptible d'entraver ou d'empêcher le fonctionnement normal des institutions républicaines.

L'état de nécessité nationale est proclamé sur toute l'étendue du territoire national, mais sa proclamation ne fait pas obstacle à la proclamation sur tout ou partie du territoire, de la loi martiale qui y est alors la seule appliquée.

La durée de l'état de nécessité est de 3 mois prolongeables indéfiniment pour la même durée.

3. La loi martiale

La loi martiale peut être proclamée en cas de péril imminent susceptible d'entraver ou d'empêcher le fonctionnement normal des institutions républicaines et résultant d'une attaque d'origine étrangère, de troubles sanglants ou d'une insurrection armée.

La loi martiale peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire. Le décret de proclamation fixe son étendue. La durée d'une loi martiale est de 3 mois prolongeables indéfiniment pour la même durée.

La loi martiale autorise le recours à la force armée pour la répression du désordre interne.

Il y a également transfert de pouvoir à l'autorité militaire notamment en matière de défense, de police et de maintien de l'ordre et la constitution de tribunal militaire d'exception pour juger des infractions commises dans le cadre de la situation exceptionnelle.

La proclamation d'une situation d'exception confère de plein droit au Président de la République, par voie réglementaire :

- d'instaurer le couvre-feu en limitant ou en interdisant la circulation des personnes et véhicules dans les lieux et heures fixés
- d'interdire le séjour, dans tout ou partie d'une circonscription à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics
- d'instaurer des zones de protection ou de sécurité dans lesquelles le séjour des personnes est réglementé
- d'ordonner la fermeture des salles de spectacles, dancing, casino, débit de boissons et de tout autre lieu ouvert au public
- d'ordonner la remise des armes de première catégorie et les munitions correspondantes détenues par des particuliers
- d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit des personnes dont les activités s'avèrent dangereuses pour l'ordre public ou la sécurité de l'État
- de prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle de la presse, des publications et des émissions de toute nature et d'interdire celles qui sont de nature à perturber l'ordre public ou à mettre en danger l'unité nationale
- de prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription ou localité de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse...

Paragraphe 2 : les limitations ou restrictions des libertés publiques

Pour être admissible, l'ingérence des pouvoirs publics dans l'exercice d'un droit ou d'une liberté garanti est subordonnée à une triple condition:

- la condition de l'égalité : l'ingérence doit être prévue par la Loi et ne peut être mise en œuvre qu'en vertu d'une disposition légale
- la condition de légitimité : l'ingérence doit viser un but légitime notamment la satisfaction de l'intérêt général, la préservation de l'ordre public ou la protection des droits et libertés d'autrui
- la condition de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité : les mesures de restriction prises doivent être nécessaires et proportionnelles au but visé.

Section 2: les acteurs et les mécanismes de protection des libertés publiques

Les libertés publiques se distinguent par leur valeur imminente dans la hiérarchie des normes et par la réglementation spécifique dont elles font l'objet. Elles sont entourées par des garanties qui sont prévues par des dispositions du droit interne et renforcées par des garanties internationales.

Paragraphe 1 : les garanties de protection interne des libertés publiques

A. Les garanties juridictionnelles

Les recours juridictionnels sont des moyens qui permettent à l'individu de présenter leur réclamation contre l'activité de l'administration ou des autres individus devant les autorités chargées de la fonction juridictionnelle.

1. Les mécanismes de contrôle

En matière de mécanisme de contrôle, on peut distinguer le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de légalité et la responsabilité du législateur du fait de la loi.

Le contrôle de constitutionnalité implique le respect de la constitution et se manifeste par le contrôle par voie d'action (a priori ou a posteriori) et par l'exception d'inconstitutionnalité (en cas d'inconstitutionnalité d'une disposition légale ou réglementaire ou en cas de violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la constitution) ;

Le contrôle de légalité constitue une garantie contre l'arbitraire et l'excès de pouvoirs de l'Administration. En matière de protection des libertés publiques, le citoyen dispose de trois sortes de recours :

L'exception d'illégalité qui est un recours par lequel le particulier poursuivi pour avoir contrevenu à une réglementation ou lors d'un procès civil soulève l'illégalité de cette disposition comme moyen devant le juge judiciaire ;

Le recours indemnitaire qui tend à réparer les dommages causés au particulier par un acte ou une activité de l'Administration ;

Le recours pour excès de pouvoir qui vise l'annulation erga omnes de l'acte estimé illégal pris par l'Administration.

La responsabilité du législateur du fait de la loi permet à la victime d'une violation d'un droit et d'une atteinte à une liberté d'engager la responsabilité de l'Etat du fait de la loi puisqu'on ne peut pas obtenir l'annulation de cette dernière. Evidemment, on ne peut pas engager directement la responsabilité du parlement, celle-ci va être subrogée par celle de l'Etat.

2. L'organisation du contrôle juridictionnel

Ici, on va voir la répartition de compétence entre les ordres de juridictions :

Le contrôle de constitutionnalité relève exclusivement de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les juridictions financières quant à elles ne participent que par extension à la protection des libertés publiques, et ce par le biais du contrôle de l'utilisation des deniers publics. Elles protègent en l'occurrence le droit de participer à la gestion des affaires publiques de l'Etat, à l'égalité devant les charges publiques et à la légalité des impositions, le droit à la transparence et à l'information sur l'utilisation des deniers publics ;

La principale répartition de compétence à faire est entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. En matière de protection des libertés publiques, la doctrine a fait la répartition selon laquelle les libertés individuelles relèvent de la compétence judiciaire et les libertés collectives de la compétence administrative.

Le législateur a également opéré une répartition de compétences entre les deux ordres de juridiction:

Matières.	Judiciaire.	Administratif.
Fiscal.	CGI 2011, Article 20.01.31 al.2. Opposition aux actes de poursuite.	CGI 2011, Article 20.01.31 al.2. Contestation des Titres de perception.
Douanes.	CD 2015, Article 302. 1°. Tribunal Correctionnel : contraventions douanières, délits de douanes, infractions au contrôle des changes, infractions mixtes des douanes et toutes les questions soulevées par voie d'exception. CD 2015, Article 302. 2°. Tribunal civil : Contestation refus de payer droits et taxes, recouvrement, contraintes, etc.	CD 2015, Article 302. 3°. Actes et décisions administratives du service des douanes.
Dommages causés par des véhicules.	Article 15 du CPP. Infractions prévues par Art. 114, 122 et 184 du CPM.	CA 23 Mars 1983 Rasolonjatovo Gaston. Si véhicule en lien avec Travaux publics ou Ouvrages publics.
Membre de l'Enseignement Public.	LTGO, Art. 228. Tribunal Civil action en responsabilité. La responsabilité de l'Etat est substituée à celle de ses agents.	
Domage causé par émeute ou attroupement.	Ordonnance 60-085 du 24 Août 1960. Auparavant : compétence judiciaire	Loi 2014-020 sur les CTD, Article 131. Actuellement : compétence administrative.
Emprise et Voie de fait.	Voie de Fait. Emprise Irrégulière (préjudicielle).	Emprise régulière.

La jurisprudence a également posé son empreinte dans cette répartition de compétences :

- La clause générale de compétence :
 - Critères de délimitation de la compétence du Juge administratif.
 - Régime administratif, service public
- La clause spéciale de compétence :

Compétence des Tribunaux judiciaires pour tout litige soulevée concernant la fonction juridictionnelle.

Le Juge administratif est incompetent pour connaître :

Des litiges qui se rattachent aux opérations de police et aux fonctions judiciaires. Arrêt CA 06 mai 1972 Dame Veuve Rakotozafy.

Des dommages causés aux plaignants à la suite d'une décision de classement sans suite du parquet. Arrêt CA 26 février 1976 Randriasony Boba Edèse.

Le Juge administratif reste compétent pour :

Les litiges relatifs à l'organisation de la Justice (création ou suppression d'une juridiction judiciaire, acte d'application du statut de la magistrature). Arrêt CA 18 octobre 1975 Ramanitra Victor.

L'appréciation des actes de nomination ou d'affectation, des mesures disciplinaires prononcées contre des Magistrats. Arrêt 02 Décembre 1978 Andrianasolo Edmond.

En matière d'emprise:

L'emprise est la prise de possession par l'Administration d'une propriété immobilière :

- Véritable dépossession (la simple atteinte ou les dommages causés à une propriété ne constituent pas une emprise). Exemple : un service public est venu occuper le terrain de Razoely pour construire une route ;
- Propriété privée et immobilière ;

Il appartient au Juge administratif d'apprécier la régularité ou l'irrégularité d'une emprise (question préjudicielle pour le Juge judiciaire).

Emprise irrégulière : fondée sur un acte illégal ou sans acte juridique préalable ou selon une procédure de prise de possession illégale. Compétence du Juge Judiciaire qui indemnise la victime, mais ne peut pas enjoindre l'Administration de faire cesser l'emprise, d'expulser le service fautif.

Emprise régulière : l'acte est légal, compétence du Juge administratif pour condamner l'Administration, notamment le service fautif.

En matière de voie de fait:

La Voie de fait est :

Une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété de la part de l'Administration (Il peut s'agir de liberté, de propriété mobilière ou immobilière) Exemple : saisie de plaque photographique, de journaux, etc.

Irrégularité grave de l'acte incriminé : l'acte insusceptible de se rattacher à l'application d'une loi ou d'un règlement.

Acte comportant des mesures insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'Administration.

Distinction par Hauriou :

Voie de fait par manque de droit : évidence d'une erreur grossière dans l'acte qui le distingue d'une simple illégalité.

Voie de fait par manque de procédure : la plus fréquente, ignorance par l'administration de la limite de ses prérogatives et complaisance des victimes.

Exemples :

Arrêt CA 05 Juillet 1969 Ralaimiza : l'Administration pénètre dans une propriété privée pour y planter des arbres et les abattre 20 ans plus tard.

Arrêt CA 07 juin 1980, Syndicat FMM c/ Fivondronampokontany Antalaha.

L'Administration prend possession d'immeubles et des constructions qui s'y trouvent pour servir de bâtiments scolaires, sans procédure normale d'expropriation.

Le juge judiciaire est compétent pour annuler l'acte administratif à la base de la voie de fait, enjoindre l'Administration de restituer et le condamner au paiement de dommages et intérêts

B. Les garanties non juridictionnelles

1. Le droit à la conscience collective

On peut distinguer deux sortes de mécanismes :

- Le droit à la pétition qui permet d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur une question déterminée ou pour adresser un message, une demande ou une opinion aux gouvernants. Il peut prendre la forme d'une plainte ou d'une collecte de signature. En droit malagasy, aucune disposition légale ne prévoit expressément ce droit à la pétition, mais pratiquement il n'est pas interdit de l'exercer.
- La résistance à l'oppression qui est la possibilité de se révolter de façon pacifique ou violente contre l'arbitraire du pouvoir public, de refuser d'obéir aux ordres. La résistance à l'oppression ou l'insurrection est le recours à la force par lequel les gouvernés tentent de se défendre. Cependant, elle peut être aussi passive sans recourir à la force.

2. L'instauration des entités administratives indépendantes

Ces entités ou autorités administratives indépendantes sont dotées de la personnalité morale. Elles sont placées en dehors de la hiérarchie administrative et disposent d'une liberté d'action juridiquement garantie et échappent à tout pouvoir d'instruction ou de reformation venant des éventuels supérieurs.

a. Le médiateur de la république

Il est institué par l'ordonnance n° 92-012 du 20 avril 1992. Le médiateur est nommé pour un mandat de 06 ans non renouvelable par le Président de la République.

Il reçoit les réclamations des citoyens concernant le fonctionnement des services publics que ce soit au niveau central qu'au niveau territorial ou au niveau des établissements publics nationaux ou locaux.

Le médiateur apprécie la qualité des SP rendus et formule des recommandations ou des propositions au vu de la résolution à l'amiable des différends et à l'amélioration du fonctionnement du service concerné. Le médiateur est informé de la suite donnée à ses

interventions et à défaut de réponse satisfaisante dans le délai fixé, il rend publiques ses recommandations sous forme de rapport spécial.

b. La commission nationale indépendante des droits de l'homme

Elle a été instituée par la loi n°2014-007 du 18 juin 2014. C'est un organisme apolitique – indépendant jouissant d'une autonomie administrative et financière. Elle est composée par des membres pluralistes et représentatifs, indépendants vis-à-vis du pouvoir et instituée par un texte fondateur de valeur constitutionnelle ou législative.

La commission est composée d'un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant du Sénat, un représentant de l'exécutif désigné par le Premier ministre, un enseignant de l'université, 07 représentants de la société civile dont un représentant d'association qui œuvre dans la protection des D de l'enfant, un représentant d'association œuvrant dans la protection des D de la femme, un représentant d'association œuvrant dans la protection des personnes handicapées, un représentant de l'ordre des avocats, de l'ordre journaliste et 02 représentants des organismes non-gouvernementaux qui œuvre dans la défense des droits de l'homme.

La CNIDH est chargée de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme sans exception ;

- Fournir au pouvoir exécutif, parlement et à la Cour suprême des avis, recommandations et rapport sur les questions de droits de l'homme ;
- Harmoniser les lois avec les instruments internationaux ;
- Encourager la ratification des instruments internationaux, interpellier le pouvoir exécutif en cas d'atteinte à des droits ;
- Recevoir et examiner des plaintes, faire des études et des enquêtes et des publications sur les droits de l'homme ;
- Coopérer avec les organes des Nations unies dans l'accomplissement de leur mission ;

c. Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit (HCDDDED)

Il est chargé de superviser l'application des principes liés à la notion d'Etat de droit, à l'application des libertés publiques, des principes de la démocratie.

Le haut conseil sert de balise aux mauvaises pratiques dans l'administration, dans les secteurs publics et les secteurs privés.

Le Haut conseil est organisé par la loi n°2015-001 du 15 janvier 2015 – c'est un organe indépendant jouissant d'une autonomie administrative et financière composée par un représentant du Président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la HCC, de la Cour Suprême, des ONG œuvrant dans la protection de la démocratie et de l'Etat de droit, un représentant de la CNIDH, de l'ordre des journalistes et de l'ordre des avocats.

Paragraphe 2 : La protection internationale des libertés publiques

Une étude typologique des garanties de protection des libertés publiques permet de distinguer le système universel de protection (système onusien) du système régional de protection (système africain).

A. Le système de protection universelle

L'Organisation des Nations Unies a organisé des protections juridictionnelles et non juridictionnelles.

1. Les mécanismes de protection juridictionnelle

La protection juridictionnelle est principalement assurée sur le plan international par la Cour pénale internationale et par la Cour internationale de justice.

a. La Cour internationale de justice

La Cour est l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle a été instituée par la Charte de l'organisation, signée en 1945 à San Francisco et a entamé ses activités en 1946 au Palais de la paix à l'Haye. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de 9 ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité.

Elle a une double mission : régler conformément au droit international les différends d'ordre juridique entre les Etats qui lui sont soumis par ces derniers et donner des avis consultatifs sur questions juridiques que lui posent les organes et les institutions spécialisées de l'ONU dûment autorisés à le faire.

Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour dans le cadre de la procédure contentieuse.

La Cour n'a pas compétence pour traiter les demandes qui lui sont présentées par des particuliers, des ONG, des entreprises ou tout autre groupement privé. Elle ne peut leur donner des consultations juridiques ni les aider dans leurs relations avec les autorités étatiques.

Il arrive néanmoins qu'un Etat prenne fait et cause pour l'un de ses ressortissants et fasse siens les griefs de ces derniers et agisse à l'encontre d'un autre Etat qui aurait violé un droit ou une liberté. Il s'agit bien dans ce cas d'un litige entre Etat mais l'Etat demandeur agit en substitution de son ressortissant.

Certes eu égard les compétences et la restriction de la saisine, la Cour ne participe pas directement à la protection des libertés publiques. Cependant, par extension, elle participe tout de même à leur protection.

Un Etat peut agir contre un autre qui aurait violé un droit ou liberté de ses ressortissants voire même pour avoir violé les droits et libertés fondamentaux des ressortissants de l'Etat à traduire devant la Cour notamment pour violation des différents textes internationaux relatifs

aux droits de l'homme ratifiés par les Etats membres, dont la Cour veille et sanctionne l'application.

Les arrêtes rendus par la Cour ou l'une de ses chambres dans les différends entre les Etats ont force obligatoire pour les parties en cause. L'article 94 de la Charte des Nations unies prévoit que chaque membre de l'organisation s'engage à se conformer à la décision de la Cour dans tout litige auquel il est partie.

Toutefois, l'exécution de la décision de la Cour se heurte toujours à la souveraineté et l'indépendance de chaque Etat éventuellement condamné. Les seules sanctions tangibles et réellement exécutoires sont les sanctions économiques (embargo, boycott). Leur exécution est conditionnée par la bonne foi et la bonne volonté des Etats.

b. La Cour pénale internationale

La Cour a été instituée par le Statut de Rome en date du 17 juillet 1998, ratifié par Madagascar le 14 mars 2008.

Elle a pour mission principale de juger contre les 4 crimes suivants et de lutter contre l'impunité surtout des dirigeants étatiques :

- Premièrement, le crime de génocide est caractérisé par l'intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux par le meurtre de ses membres ou par d'autres moyens : atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; ou transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
- Deuxièmement, la CPI peut engager des poursuites pour des crimes contre l'humanité, qui sont de graves violations commises dans le cadre d'une attaque de grande envergure lancée contre toute population civile. Les 15 formes de crimes contre l'humanité énumérées dans le Statut de Rome comprennent des délits tels que le meurtre, le viol, l'emprisonnement, les disparitions forcées, la réduction en esclavage, notamment celle des femmes et des enfants, l'esclavage sexuel, la torture, l'apartheid et la déportation.
- Troisièmement, les crimes de guerre, qui constituent des infractions graves aux Conventions de Genève dans le contexte d'un conflit armé et comprennent, par exemple, le fait d'utiliser des enfants soldats ; le fait de tuer ou de torturer des personnes telles que des civils ou des prisonniers de guerre ; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des hôpitaux, des monuments historiques, ou des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative.
- Enfin, le quatrième crime relevant de la compétence de la CPI est le crime d'agression. Il s'agit de l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance d'un autre Etat. La définition de ce crime a été adoptée en apportant

des amendements au Statut de Rome lors de la première Conférence de révision du Statut qui s'est tenue à Kampala (Ouganda) en 2010.

Mais actuellement, les écologistes tentent d'introduire parmi les compétences de la Cour le crime d'écocide ou suicide écologique qui consiste en la destruction ou l'endommagement irréversible d'un écosystème notamment par un processus d'écophagie qui traduit la surexploitation d'un écosystème, intentionnelle ou non.

La cour ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou la capacité pour juger des crimes internationaux (principes de complémentarité). En d'autres termes, la Cour n'intervient que lorsque les systèmes internes sont défectueux ou en cas d'épuisement des voies de recours internes et ce sans satisfaction.

La Cour est composée de 18 juges élus par l'Assemblée générale des Etats membres pour un mandat de 9 ans renouvelables.

2. Les mécanismes de protection non juridictionnelle

Les mécanismes de protection non juridictionnelle ont été prévus et institués par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Chaque texte prévoit en principe, un mécanisme de contrôle et de protection des droits qui y sont reconnus.

La Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques ont instauré respectivement le Haut commissariat des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme.

a. Le Haut commissariat des droits de l'homme

Le haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme représente l'engagement de la Communauté internationale envers la promotion et la protection de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés prévus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

L'Assemblée générale des Nations unies a créé le Haut commissariat en décembre 1993 par la résolution n°48/41.

Le Haut commissariat a plusieurs rôles particuliers à jouer :

- Promouvoir et protéger les droits de l'homme : il s'exprime objectivement en cas de violation des droits de l'homme et aide à définir les normes servant à évaluer les progrès réalisés en matière de droits de l'homme à l'échelle mondiale ;
- Aider à autonomiser les individus : ses activités de recherche, de plaidoyer et d'éducation contribuent à sensibiliser et mobiliser la communauté internationale et l'opinion publique sur les questions relatives aux droits de l'homme. Son action permet à des milliers de personnes dans toutes les régions du monde de faire valoir leurs droits ;

- Fournir une assistance aux gouvernements grâce à ses présences sur le terrain : il aide à prévenir les abus et à désamorcer certaines situations susceptibles de générer des conflits. Son travail de surveillance et d'analyse permet de prendre des décisions et de concevoir de programme de développement adapté. Il fournit également des services de renforcement des capacités et de conseils juridiques à des milliers de personnes en soutenant la conception et l'adoption des lois et politiques judicieuses dans le monde entier ;
- Intégrer les droits de l'homme dans tous les programmes des Nations unies afin de garantir la paix et la sécurité et le développement.

b. Le comité des droits de l'homme

Le PIDCP a institué un mécanisme de contrôle qui permet à la communauté internationale d'apprécier l'application de ses dispositions par les Etats parties.

Cette mission de contrôle est confiée au Comité des droits de l'homme est régi par le premier protocole facultatif au pacte.

Ce contrôle se concrétise pratiquement au moyen de rapports présentés par les Etats parties d'une part et à travers les communications et les plaintes adressées par les organisations et les particuliers qui prétendent victimes de violation d'un droit ou d'une liberté reconnus dans le pacte.

Madagascar a approuvé son adhésion au pacte et à son protocole facultatif par la loi n°70-001 du 23 juin 1970 et a procédé à la ratification le 21 juin 1971. En ratifiant le pacte et son protocole, on accepte la compétence du Comité dans le règlement des différends nés de la violation de leurs dispositions.

Les communications ou les plaintes sont les moyens par excellence pour mettre en œuvre la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. Le Comité peut tenir des séances privées afin d'examiner les plaintes qui émanent des Etats parties contre un autre et des particuliers et des communications provenant des organisations gouvernementales ou non. Mais il est rare que le Comité soit saisi d'une plainte d'un Etat contre un autre par rapport aux plaintes déposées par les particuliers contre leur Etat.

La saisine du Comité est subordonnée à l'épuisement des voies de recours internes et à l'inexistence de recours parallèle. Le requérant peut être la victime elle-même ou les proches et les organisations non gouvernementales qui peuvent agir au nom de la victime depuis l'élargissement de la notion de victime potentielle.

Le Comité formule des recommandations qui concernent les mesures à prendre pour rétablir la situation.

Le système des rapports par ailleurs reste un mécanisme de contrôle et de supervision important bien qu'il soit reconnu comme étant le plus faible par rapport au système des plaintes. Il n'offre pas de garantie réelle de recours pour les victimes.

Il y a lieu de distinguer 2 mécanismes de rapport prévus par le PIDCP :

Le rapport initial adressé au Comité dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du pacte dans chaque Etat partie ;

Le rapport périodique présenté chaque fois que le Comité en fait la demande et dont les Etats doivent présenter chaque année à la conférence organisée par le Comité.

Le Comité examine les rapports et adresse des observations générales qu'il juge appropriées. Ces observations peuvent se traduire par des constats de violations des dispositions du pacte ou des constats de non-conformité du droit positif d'un Etat aux dispositions du pacte.

Le Comité des droits de l'homme est composé de 18 experts indépendants, de haute moralité et possédant de compétences reconnues dans le domaine des droits de l'homme, et élus pour 4 ans par les Etats parties.

B. Le système de protection régionale

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples institue deux mécanismes de protection : la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

1. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Elle chargée du contrôle de la mise en œuvre des droits et obligations prévus par la Charte. Sa mission tourne autour de trois fonctions :

- Une fonction d'étude et d'information visant à sensibiliser l'opinion publique africaine à la question de droits de l'homme ;
- Une fonction quasi-législative par la préparation des projets de loi cadre à l'intention des Etats ou à l'intention de l'Union africaine ;
- Une fonction de coopération dans le but d'entretenir les liens avec les organismes africains ou encore onusiens.

La Commission joue un rôle consultatif en émettant des avis ou en interprétant les dispositions de la Charte à la lumière du droit positif des Etats ou à la lumière du droit international.

2. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

La Cour instituée par le protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adopté le 10 juin 1998. Le protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004.

La Cour remédie aux insuffisances de la Commission et permet de renforcer les mécanismes nationaux mis en place par les Etats.

La Cour fonctionne parallèlement à la Commission. Elle a une compétence contentieuse et consultative. La compétence contentieuse de la Cour s'applique à toutes les affaires et à tous les différends qui lui sont soumis en ce qui concerne l'application de la Charte, du protocole ou de tout autre instrument relatif aux droits de l'homme ratifié par les Etats concernés.

Pour sa compétence consultative, la Cour peut à la demande d'un Etat membre de l'Union africaine ou de l'un de ses organes ou toute autre organisation donner un avis sur toute autre question juridique relative à la charte ou tout autre instrument à condition que l'avis n'est pas lié à une question examinée par la Commission.

La Cour est composée de 11 juges qui sont des ressortissants des Etats parties, élus pour un mandat de 6 ans renouvelables une fois.

L'article 34 du protocole instituant la Cour prévoit qu'au moment de la ratification de ce Protocole ou à tout moment par la suite, l'Etat fera une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des affaires en vertu de l'article 5 (3) de ce Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en vertu de l'article 5, paragraphe 3, impliquant un Etat qui n'a pas fait une telle déclaration. Or, jusqu'à présent, seuls 12 pays ont fait cette déclaration et Madagascar ne figure pas encore dans la liste.